

1513975-44.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... RODRIGUEZ pela prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, porque, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 15h15min, na Rua Nelson Cruz, altura do nº 53, bairro Belém, nesta cidade e Comarca da Capital, os acusados traziam consigo e vendiam, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, para fins de tráfico, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513975-44.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513975-44.2022.8.26.0228 PD 804/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO PEREIRA DA SILVA e outros

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 26 de julho de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Dra. Anne Marie Lourenço Karsten, presentes os réus Roberto Pereira da Silva, Matheus Gabriel Pereira da Hora e Santiago Sepulveda Rodriguez, acompanhados pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado os interrogatórios dos réus nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarada encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, rata-se de ação penal deflagrada em face de ROBERTO PEREIRA DA SILVA, MATHEUS GABRIEL PEREIRA DA HORA e SANTIAGO SEPULVEDA RODRIGUEZ pela prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, porque, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 15h15min, na Rua Nelson Cruz, altura do nº 53, bairro Belém, nesta cidade e

Comarca da Capital, os acusados traziam consigo e vendiam, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, para fins de tráfico, 108 porções de crack, 107 porções de cocaína, 148 porções de maconha, 16 porções de lança-perfume e 01 porção de ecstasy (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16/18 e laudo de constatação de fls. 21/29). Ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, eles se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes. Regularmente processado o feito, com a citação dos réus e a apresentação de resposta à acusação, designou-se a presente audiência de instrução e julgamento. Assim, não há questões aptas a comprometer o mérito da presente ação penal. 2. MÉRITO: Como se verá a seguir, o conjunto probatório reunido nos autos permite a formação de um juízo seguro de convicção quanto à prática dos crimes descritos na denúncia por parte dos acusados, sendo típico, antijurídico e culpável. 2.1 MATERIALIDADE E PROVA DOCUMENTAL: A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 1, 80 fls. 08/14; auto de exibição e apreensão fls. 16/18; laudo constatação fls. 21/29; laudo químico-toxicológico fls. 248/253; laudo celular fls. 254/256, 257/259; laudo da agenda e anotações juntados nesta data e demais prova oral colhida em ambas as fases. 2.1 AUTORIA E PROVA ORAL: A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre os réus. O Policial Civil RENAN SOUZA DA SILVA declarou que receberam uma informação que na região estava ocorrendo tráfico de drogas, então, deslocaram-se até o local, onde visualizaram uma grande movimentação de usuários e três indivíduos vendendo os entorpecentes na forma de "drive thru", já que as motocicletas, carros e pessoas a pé apenas paravam por instantes, recebiam algo, e depois partiam. Os três ficavam juntos, nitidamente, sendo todos responsáveis por entregar os entorpecentes. Tem certeza de que Matheus estava no mesmo local em data anterior, efetuando a venda, quanto a Roberto e Santiago não tem como reconhecê-los, porque era necessário passar com a viatura em velocidade. Apreenderam com os três entorpecentes, além de dinheiros. Em entrevista informal, eles permaneceram em silêncio. Foi apurado que eles não residiam na localidade. Em diligências anteriores, passaram pelo local cerca de três vezes, sempre visualizando a movimentação do comércio de entorpecentes. As anotações apreendidas em posse dos acusados são típicas de traficância, estando discriminados os tipos de entorpecentes "md, SK -skunk-, maconha de 20 e maconha de 50 etc". O Policial Civil HEITOR TADEU NOGUEIRA trouxe versão similar, acrescentando que os acusados são apenas a ponta do comércio, normalmente repassando o "recolhe" para os donos das "biqueiras". Por fim, o Policial Civil MARCELO MIRANDA DA SILVA relatou que receberam uma denúncia no departamento, informando da prática de tráfico de drogas em frente a uma igreja. Foram ao local a bordo de uma viatura de descaracterizada, onde visualizaram a presença de três indivíduos com bolsas fazendo a venda de entorpecentes, na forma de "drive-thru", já que passam lá automóveis, motos e pessoas a pé. Não conseguem se aproximar de viatura caracterizada, uma vez que eles fogem por uma viela para dentro da comunidade. Após a abordagem, foi ao local em apoio. Na fase policial, os acusados permaneceram em silêncio (fls. 5-7). Sob o crivo do contraditório, o réu Roberto afirmou que mora na Comunidade de Heliópolis e foi convidado por terceiro para receber R\$ 150,00 para vender drogas em Belém, o qual lhe deixou no local de manhã cedo e lhe pegaria às 19 horas. Afirmou que cada um faz um ponto de venda no local, afirmando desconhecer Matheus e Santiago. Quanto às anotações da contabilidade (fls. 262-265), quis fazer crer que o indivíduo, que não identificou, já lhe entregou preenchido. Disse que tinha mais dinheiro que os demais, porque o outro indivíduo, que lhe cooptou, não havia passado no local. Era seu "primeiro dia" de trabalho. O acusado Matheus, que estava em regime aberto há três semanas, em suas palavras "no mundão", após condenação anterior por tráfico de drogas, disse que foi chamado por um amigo antigo para traficar no ponto onde foi abordado. Negou que efetuasse a contabilidade do tráfico, muito embora o caderno tenha sido apreendido em sua posse. Questionado sobre as iniciais ou "códigos", soube descrever que AL é maconha e que recolher é o valor auferido, logo, tinha conhecimento do que preenchia. Disse que era seu "primeiro dia" no ponto, embora os policiais civis os tenham visto antes no ponto, dizendo que estava lá para comprar drogas, embora não resida naquela comunidade. Ademais, negou conhecer Roberto e

Santiago, embora dividissem o mesmo ponto de drogas, reconhecendo que não é comum que vendedores de “donos de biqueiras” diversas atuem no mesmo local. O réu Santiago afirmou que chegou no local ao meio-dia e que não conhecia Matheus e Roberto. Disse que era seu “primeiro de trabalho”. Disse que não sabe quem é o “dono da biqueira”, tampouco se os demais trabalhavam para ele. Afirmou que fazia suas anotações num papel próprio. Assim, cotejando a prova documental e os depoimentos colhidos na fase policial e sob o crivo do contraditório, a condenação é medida que se impõe. Com efeito, as diligências empreendidas pela Polícia Civil, previamente à prisão em flagrante, demonstraram que os acusados vendiam, conjuntamente, entorpecentes naquele ponto. Além disso, as anotações de contabilidade, juntadas nesta data, confirmam a organização e estrutura do grupo, inclusive, em posse de Roberto havia três campos “AL”, “H” e “J”, indicando os três acusados, bem como o “recolhe” efetuado pelo superior hierárquico. Já na agenda de Matheus, eram discriminadas as quantidades de entorpecentes vendidas, por exemplo, “M20” e “M50” referem-se à maconha. Inclusive, aponta-se o total de R\$ 6.260,00 auferido em um único dia. Ademais, foi apreendido dinheiro proveniente da prática ilícita em posse deles. Destarte, é notório o vínculo associativo existente entre eles e terceiros não identificados, afinal, é certo que eles integram a cadeia de distribuição de entorpecentes daquela região, possuindo acesso ao fornecedor, que lhes entrega vasta quantidade e variedade de entorpecentes, e deslocam-se ao ponto de venda de forma rotineira. Ao final do dia, “recolhem” o dinheiro para o superior. Não há que se cogitar que os três comercializavam no mesmo local e não possuíam qualquer vínculo entre si.

3. DOSIMETRIA DA PENA: Inicialmente, insta salientar que em seu artigo 5º, XLVI, a Constituição Federal tratou do princípio da individualização da pena, ao dispor que “a lei regulará a individualização da pena [...]”. Em atenção ao mandamento constitucional, o legislador ordinário tratou das circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal. Cada delito tem as suas características próprias. Do mesmo modo, cada indivíduo carrega consigo condições pessoais que lhe são inerentes. Daí a necessidade de individualizar as penas, o que significa adequar a reprimenda penal ao crime efetivamente praticado, bem como ao seu autor. Tal necessidade está intrinsecamente ligada ao princípio da isonomia. Exatamente por isso que o preceito secundário dos tipos penais não prevê pena determinada, mas determinável, a ser fixada pelo julgador com observância dos parâmetros mínimos e máximos estabelecidos pelo legislador. E, tratando-se do crime de tráfico de drogas, ainda há que se cotejar o artigo 42 da Lei n. 11.343/06. Dito isso, na primeira fase, deve a pena base ser majorada em decorrência da variedade das drogas, além da maior nocividade à saúde pública destas substâncias, notadamente o crack e a cocaína, que possuem alto índice viciante, geradoras de invencíveis problemas na saúde pública, tanto que, nesta cidade de São Paulo, há até mesmo uma região designada vulgarmente como “cracolândia”, um retrato dramático da complexidade do problema social envolvendo a disseminação irrefreada dessas substâncias. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica quanto aos acusados Roberto e Matheus. De outro lado, há a atenuante da menoridade relativa em relação a Santiago e Matheus. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, os réus nada mais fizeram que endossar a segura prova já produzida, de modo que resta afastada a súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, já que a admissão não precisa ser valorada para a condenação. Ademais, a mera menção que estavam “traficando”, sem fornecer maiores detalhes no intuito de proteger o restante da cadeia de distribuição de entorpecentes, não pode ser considerada. Com relação à terceira fase da fixação da reprimenda, é inviável reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Primeiro, Roberto e Matheus são reincidentes específico, enquanto Matheus foi condenado recentemente por tráfico de drogas. Segundo, as circunstâncias da prisão demonstram que eles se dedicam à atividade criminosa. Terceiro, a própria imputação da associação para o tráfico afasta completamente a possibilidade de incidir a presente minorante. Quanto ao regime prisional, requeiro seja fixado o fechado em decorrência da pena aplicada somada às circunstâncias judiciais negativas e a reincidência de Matheus e Roberto.

4. CONCLUSÃO: Diante do exposto, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia,

reconhecendo-se as questões apontadas com relação à dosimetria da pena. Por fim, requeiro seja decreta a bem dos valores e objetos apreendidos em posse dos acusados, pois proveniente de ilícito.” Dada a palavra à Dr(a). Defensora dos réus, assim se manifestou: “MM. Juiz, ROBERTO PEREIRA DA SILVA, MATHEUS GABRIEL PEREIRA DA HORA E SANTIAGO SEPULVEDA RODRIGUEZ, já qualificados nos autos da ação penal em epígrafe, vêm, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais, da forma que segue. Os réus foram denunciados como incurso no artigo 33, caput e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, pelos fatos descritos na denúncia. Os acusados foram notificados, foi apresentada defesa prévia e a denúncia foi recebida. Durante a instrução probatória, foram inquiridos três policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante e os acusados foram interrogados ao final. Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. Contudo, em que pese a manifestação ministerial, a ação penal é improcedente, como de passa a demonstrar. O PC MARCELO MIRANDA DA SILVA veio informação de que estava havendo tráfico de drogas na região do Belém perto de uma igreja. O depoente ficou com viatura caracterizada próximo ao local. Outra equipe com viatura descaracterizada fez a abordagem e chamou o depoente para acompanhar. Soube que havia três indivíduos vendendo droga no local. Não participou da investigação; o pessoal disse que eles vendem para quem passa, seja a pé, de carro ou de moto. Tem uma viela que eles se escondem, por isso não dá para ir de viatura caracterizada. Os colegas do depoente com viatura descaracterizada. O depoente chegou no apoio e conduziu para a delegacia. Foi bem rápido, a denúncia chegou e no mesmo dia já constaram no local que havia venda. Não foi investigação demorada. A informação falava que vendiam em frente a igreja. Não se recorda o nome da comunidade em uma travessa da Av. Celso Garcia. O depoente não foi até o local, parou com a viatura antes do local delatado. O PC RENAN SOUZA DA SILVA, em juízo, relatou que receberam denúncia de tráfico de entorpecentes. Diligenciaram até o local e perceberam movimentação típica de drive-thru e de usuários. Viram que pegam algo e entregavam algo. Montaram mini operação e realizaram abordagem. As pessoas na região pareciam usuários. Os réus ficaram todos juntos. Ele recebia, aproximava-se dos outros dois trocavam o dinheiro pela droga. Todos foram pagos com bolsinha com entorpecente. O pessoal encostava de carro ou de moto, eles se aproximavam, pegavam alguma coisa e iam embora. O depoente desceu a pé e quando foi abordar o Roberto, Matheus já empreendeu fuga. Foi pego pelo seu parceiro. Santiago estava sentado na cadeira e continuou. Havia alguns papeis com anotações como se fosse contabilidade. Foi apreendido dinheiro em espécie. O local é ponto de tráfico; não conhecia os réus. no dia anterior, quando foram ver o local, avistou Matheus. Roberto e Santiago não conseguiu identificar. Viu que tinha mais pessoas, mas não conseguiu reconhece-los. No momento da abordagem, Matheus disse que era usuário. Nenhum dos três eram moradores da região. Teve contato com os papeis, mas não se recorda como eram pelo decurso do tempo. Acredita que o papel indicado pela promotora como espécie de drogas e outra informação como quantidades. Acredita que o valor escrito recolhe pode ser o repassado para os superiores, mas pode não ser só isso, é anotação relativo às drogas. Não consegue ter clareza para saber se alguém era responsável pela recolha das drogas. Roberto era quem tinha mais dinheiro. Não tiveram informação de que os réus integram organização criminosa. Recorda-se que só réus tinham tatuagem, mas não se recorda quais. A informação que chegou ao DENARC não tinha características de pessoas, somente informava que o local era ponto de venda de drogas. Passaram rapidamente pelo local por três vezes e foi possível ver movimentação. Ficaram em campana por poucos momentos, poucos minutos. Roberto e Santiago se calaram. Somente os três réus foram abordados. O PC HEITOR TADEU NOGUEIRA declarou que foi oriundo de uma denúncia de tráfico de drogas em comunidade da celso Garcia. Fizeram diligências e verificaram que havia tráfico na porta da igreja. Abordaram os acusados e havia pochetes com droga em grande quantidade para venda, que era feita pelo sistema drive-thru, as pessoas eram servidas de forma livre. Com os três acusados foram apreendidos drogas e dinheiro. Havia lança, crack e mais tipos de droga. Com um deles foi pego R\$150,00, com outro

R\$450,00 e com outro quantia menor, não se recorda quanto. Havia um papel com algumas anotações que parecia uma contabilidade em lápis ou caneta que foi apreendida. Os três réus que estavam no local portando sacolas com drogas. Matheus tentou empreender fuga, mas foi contido e algemado. Era denúncia anônima que gerou nota de serviço, só participou no dia da prisão. Não se recorda do teor das anotações, não pegou para analisar. Não tem condições de informar do que se tratam as anotações. Acredita que não sejam os réus que fiquem com o dinheiro, mas sim algum superior. No momento da abordagem, eles disseram que não era deles as drogas. Não conhecia os réus de abordagem. Passaram com carro descaracterizados, viram eles agindo, retornaram e abordagem os réus, que estavam com as drogas. Somente os três foram abordados. Ação foi muito rápida, não tiveram tempo nem reação. Não verificaram se algum era olheiro. Bolsa azul com Santiago e duas sacolas pretas, uma com Roberto e outra com Matheus. Interrogado, ROBERTO PEREIRA DA SILVA declarou que estava na comunidade de Heliópolis e chegou um rapaz e ofereceu R\$150,00 para trabalhar na favela do Belém. Mora com o pai, que está desempregado e é de idade. Aceitou a proposta. Isso foi por volta de 9h da manhã; por volta das 16h foi detido. No local, são três pontos independentes, não faz parte de um ponto só. O rapaz que levou o soltou lá e ficou lá trabalhando. Estava com quantia maior de dinheiro porque do horário que chegou pela manhã até o horário que foi preso estava no local. Conheceu Roberto e Santiago no dia dos fatos. Ficavam próximos. Está arrependido. Tinha papel de anotação das drogas, não tinha relação com as vendas do Santiago e Roberto. Estava anotado o que a pessoa que deixou lá entregou. Não conhece o dono do ponto. O rapaz levou o réu de Uber até o local do ponto. O rapaz falou que às 19h voltaria para pegar as coisas e o réu poderia ir embora. O papel com anotação foi entregue pelo rapaz e não acrescentou nenhuma anotação. Em seu interrogatório, MATHEUS GABRIEL PEREIRA DA HORA confessou a traficância. Afirmou que não agia junto com Santiago e Roberto, era individual. Conheceu os demais réus no mesmo dia que foi preso. Estava com droga e dinheiro. Não era responsável pelo preenchimento. Quando davam para vender já vinha com anotação para saber quanto de droga estava com o réu. Não fez anotação no caderno, já vinha assim. Não sabe explicar os números que a promotora indicou. Estava com papel que estava escrito AL, que significa maconha. Só entregava o dinheiro quando acabava o plantão e entregava o dinheiro para outra pessoa, que é quem dá a droga para vender. Não conhecia Roberto e Santiago. Não sabe se era o mesmo fornecedor no ponto. Um colega chamou para trabalhar no ponto para ganhar um dinheiro. SANTIAGO SEPULVEDA RODRIGUEZ, em seu interrogatório judicial, confessou o tráfico. Era a primeira vez que traficava. Trabalha com costura em casa, mora junto com mãe irmã. O trabalho estava fraco, passando necessidade, o aluguel estava atrasado. Ficou desesperado e decidiu encostar na favela e encontrou um rapaz que perguntou se queria trabalhar, acabou aceitando. Saiu de sua casa por volta do 12h, pegou a bolsa por volta das 13h e pouco tempo depois foi preso. Conheceu Matheus e Roberto no dia da prisão. Tem 18 anos de idade. Um rapaz na favela perguntou se queria trabalhar, não sabe o nome do rapaz, não usam o nome verdadeiro. O rapaz que chamou que deu as drogas para vender. Não passou pelo momento do recolhe porque fazia 1h30 que estava no local quando foi preso. A indicação era guardar o dinheiro até as 19h, horário do final do plantão. Não anotou nada porque não teve nenhum gasto. Tinha um pedaço de papel para anotar seus gastos. Não sabe se trabalhavam para o mesmo ponto de biqueira. Pelo que entendeu que cada um vendia para uma pessoa. É usuário de maconha e comprava ali mesmo na favela. Apesar da confissão dos acusados com relação ao tráfico de drogas, percebe-se que se trata, portanto, de um caso no qual repousam sérias dúvidas acerca da configuração delitiva. Não há provas cabais de autoria delitiva, pois a confissão não é rainha das provas e é necessário analisá-la em conjunto com as demais provas dos autos. Apesar da abordagem ter ocorrido em local movimentado, nenhuma testemunha civil foi arrolada e ouvida em juízo. No presente feito, de fato, não há qualquer prova concreta do crime de associação, já que inexistente notícia de estabilidade ou permanência. A prisão dos réus no mesmo local e dia foi fortuita. Os próprios policiais civis mencionaram que a denúncia anônima que deflagrou a ordem de serviço somente mencionou o local, não características de pessoas. Não houve campana, não

houve investigação prévia. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento CONSOLIDADO nesse sentido (STJ - HC: 108359 MS 2008/0127780-5). O mero fato de existir mais de um réu não ultrapassou o simples concurso de agentes, que, a toda evidência, não poderia ter acontecido. Ademais, as provas dos autos apontaram tão somente para apreensão de entorpecentes com um corréu. Para tal aplicação, deve haver inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre os agentes tenha sido assentada com essa precisa finalidade de constituir sociedade espúria para a comercialização de entorpecentes, o que não ocorreu no presente feito. A denúncia anônima foi no mesmo dia da abordagem e não houve, portanto, investigação prévia. Sequer campanha foi realizada, de acordo com o depoimento do policial. De tudo quanto exposto, se depreende que, ao menos, resta dúvida fundada, que deve ser interpretada em favor dos réus, por imposição do estado constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII). A incerteza não compactua com o juízo normativo exigido para a condenação. Desse modo, requer-se a ABSOLVIÇÃO dos acusados nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal de todos os delitos a eles imputados. Em caso de eventual condenação pelos delitos imputados na denúncia, requer seja a pena base fixada no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos artigos 59 Código penal e 42 da Lei nº 11.343/06, ressaltando-se que Santiago é primário e de bons antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, requer-se o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão e da menoridade com relação a Santiago, superando o entendimento da Súmula 231 do STJ em razão do princípio da individualização da pena. Também deve ser reconhecida a atenuante a menoridade relativa com relação a MATHEUS. Da mesma forma, no tocante aos acusados ROBERTO e MATHEUS requer-se o reconhecimento da atenuante da confissão judicial, nos termos da Súmula 545 do STJ, compensando integralmente com a reincidência. Requer ainda a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, tendo em vista que SANTIAGO é primário, tem bons antecedentes e que não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. A mesma sorte assiste a ROBERTO e MATHEUS, pois, caso reconhecida reincidência, na terceira fase, como medida de proporcionalidade, evitando-se o abominável bis in idem, deve-se reconhecer o privilégio previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. A causa de diminuição em apreço não pode ser afastada em razão de reincidência eventualmente reconhecida na segunda fase da dosimetria penal, por refletir inegável bis in idem, pois a mesma circunstância está sendo valorada em dois momentos distintos. Requer seja fixado o regime inicial menos gravoso para MATHEUS E ROBERTO e regime aberto para SANTIAGO, nos termos do artigo 33, §2º, "b" e "c" do Código Penal, eis que presentes todos os seus requisitos. Deve-se ter por claro que o Pretório Excelso pacificou entendimento em seu Pleno de que é inconstitucional a previsão de obrigatoriedade de regime inicial fechado da Lei dos Crimes Hediondos (art. 1º, §1º), no HC 111.840/ES. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal e na Resolução nº 5/12 do Senado Federal com relação a SANTIAGO. Por fim, finda a instrução criminal e ausentes as hipóteses ensejadoras da constrição cautelar, requer o direito de apelar de eventual sentença condenatória em liberdade." Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. ROBERTO PEREIRA DA SILVA (qualificado a fls. 31), MATHEUS GABRIEL PEREIRA DA HORA (qualificado a fls. 53) e SANTIAGO SEPULVEDA RODRIGUEZ (qualificado a fls. 71), foram denunciados a fls. 143/146 como incursos nos artigos 33, "caput" e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, porque em 15 de junho de 2022, por volta das 15h15min, na Rua Nelson Cruz, altura do nº53, bairro Belém, nesta Cidade e Comarca da Capital, em tese previamente associados de forma estável, habitual e permanente para o cometimento do tráfico ilícito de drogas, traziam consigo e vendiam, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 108 porções de crack, 107 porções de cocaína, 148 porções de maconha, 16 porções de lança-perfume e 01 porção de ecstasy (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16/18, laudo de constatação de fls. 21/29 e L.E.Q.T. de fls. 248/253). Os réus foram presos em flagrante delito por Policiais Civis e permaneceram custodiados no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 149/152),

os réus foram citados (fls. 232, 234 e 236), sendo apresentada resposta à acusação (fls. 270). Durante a instrução criminal foram ouvidos 03 (três) Policiais Civis responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados. Roberto, Matheus e Santiano foram ao final interrogados e as partes debateram oralmente. O Ministério Público, em sua manifestação, pediu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição. Subsidiariamente pretendeu: a imposição das penas-bases no patamar mínimo; o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão para os três acusados; a aplicação ainda da atenuante da menoridade com relação a Santiago; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06; a fixação do regime inicial menos gravoso para MATHEUS e ROBERTO e o regime aberto para SANTIAGO, nos termos do artigo 33, §2º, "b" e "c" do Código Penal; a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente em parte. De fato, há prova cabal no tocante aos três acusados, quanto ao cometimento do delito do artigo 33 da Lei de Drogas. Em contrapartida, em que pese o pleito do "Parquet", o crime de associação para o tráfico não ficou suficientemente provado. Isto porque, a prova colhida em Juízo não demonstrou de forma inequívoca, que os três acusados estivessem previamente conluiados, de forma estável, habitual e permanente, para o cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes. Vejamos. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo B.O. de fls. 08/14; pelo A.E.A. de fls. 16/18; pelo laudo de constatação de fls. 21/29; pelo L.E.Q.T. de fls. 248/253; pelo laudo dos papeis e agenda com contabilidade do tráfico (fls. 262/269); pelos depoimentos prestados pelos Policiais Civis nas duas fases procedimentais; e pelo teor da confissão judicial dos acusados, interrogados na presente data, quanto ao delito do artigo 33 da Lei de Drogas. Ouvidos na fase policial e em Juízo, os policiais Renan, Heitor e Marcelo prestaram versões uníssonas e críveis. Narraram que se dirigiram ao local dos fatos para averiguar notícias de tráfico de drogas em sistema de "drive-thru", ou seja, usuários de droga passavam a pé, de carro ou de motocicleta, faziam rapidamente o pagamento correspondente a droga solicitada e já deixavam em seguida o local, na posse das porções adquiridas. Esse sistema de tráfico já era conhecido da Polícia naquele ponto de venda de drogas da Zona Leste da Capital (cf. informe criminal nº14.289.22-3 - fls.15). Assim sendo, Renan e Heitor seguiram à frente, ao passo que Marcelo ficou na retaguarda, para prestar apoio. No momento em que Renan e Heitor se aproximaram do ponto de venda e passaram a observar o movimento do tráfico, logo identificaram os três acusados, como responsáveis pelo ilícito comércio. Durante a observação puderam confirmar que os três acusados participavam do tal esquema de "drive thru", ou seja, usuários compradores se aproximavam a pé, de carro ou de moto, faziam o pagamento e na sequência recebiam as drogas, deixando o local. Uma vez identificados SANTIAGO, ROBERTO e MATHEUS, na condição de traficantes responsáveis pelas vendas, procederam às abordagens dos mesmos. Em busca pessoal, foi encontrada em poder de MATHEUS uma pochete verde, contendo R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, uma agenda pequena, bem como porções de maconha, cocaína, lança-perfume e ecstasy. Já em poder de SANTIAGO foi encontrada uma bolsa da marca Puma, em cujo interior foram encontrados um aparelho celular, a quantia de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) em notas trocadas, anotações manuscritas, além de porções de maconha, lança-perfume e crack. Por sua vez, em poder de ROBERTO, foi encontrada uma pochete rosa, contendo um aparelho celular, a quantia de R\$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) em dinheiro, anotações manuscritas e porções de skunk, maconha, cocaína e crack (cf. auto de exibição e apreensão de fls.16/18). Indagados em Juízo os Policiais Civis sobre a imputação de prévia associação por parte dos três acusados, na atividade do tráfico de drogas, verificou-se que Renan, Heitor e Marcelo não souberam dizer se realmente havia prévia associação, de caráter estável e habitual

entre Roberto, Matheus e Santiago, para o comércio ilícito de entorpecentes. Apenas Matheus teria sido visto anteriormente pelo local, mas desacompanhado de Roberto e Santiago, sem cabal aferição se na data pregressa, o mesmo realmente estaria fazendo a venda de drogas. Portanto, de acordo com a palavra dos policiais,

os réus foram flagrados fazendo a venda de drogas naquela data específica do flagrante, não havendo elementos para caracterizar de forma autônoma, o delito do art. 35 da Lei de Drogas. Por sua vez, interrogados em Juízo, os réus Roberto, Matheus e Santiago admitiram de forma espontânea, a posse das drogas e do numerário consigo apreendidos. No entanto, ressaltaram que cada qual agia de forma independente dos demais, tendo se conhecido apenas no dia da prisão em flagrante, negando portanto o delito de associação para o tráfico. Destarte, incontroverso restou o cometimento do crime do artigo 33 da Lei de Drogas, mas com relação ao crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, há de se convir que não há prova suficiente para condenação. Mister se faz a responsabilização dos acusados tão somente pelo crime de tráfico de drogas, ao qual se subsumiu o flagrante, frisando-se que não houve qualquer investigação prévia ou demais elementos, a demonstrar a ocorrência do delito do artigo 35 da Lei de Drogas. Passo à dosagem das penas. Na fase do artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base para os réus Roberto, Matheus e Santiago, no tocante do delito do artigo 33 da Lei de Drogas, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase de dosimetria da pena, verifico que Roberto e Matheus são reincidentes, cf. certidões de fls. 91/92, 88/89 e 177/179. Em contrapartida, Roberto e Matheus foram réus confessos em Juízo, pelo que compenso a agravante do art. 61, I, do CP, com a atenuante do art. 65, III, d, do CP, mantendo suas penas em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Para o réu Santiago há duas atenuantes (confissão e menoridade penal relativa), mas sua pena-base já foi fixada no patamar mínimo. Na terceira fase de dosimetria de pena, quanto aos réus Roberto e Matheus, não cabe a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, visto que são reincidentes técnicos. Já com relação ao réu Santiago, por considerá-lo tecnicamente primário e sem antecedentes, aplico o disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. Assim, reduzo a pena de Santiago em 2/3 (dois terços), o que perfaz, em definitivo, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso. Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação penal para: a) CONDENAR o réu ROBERTO PEREIRA DA SILVA, RG/SP 38.218.602 e CPF 449.908.038-09, bem como o réu MATHEUS GABRIEL PEREIRA DA HORA, RG/SP 65.477.538, ao cumprimento 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-os como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal; b) CONDENAR o réu SANTIAGO SEPULVEDA RODRIGUEZ, RG/SP 81.017.859 e CPF 900.381.888-64, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06; e c) ABSOLVER os réus ROBERTO PEREIRA DA SILVA, MATHEUS GABRIEL PEREIRA DA HORA e SANTIAGO SEPULVEDA RODRIGUEZ, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, do delito tipificado no artigo 35, "caput", da Lei nº. 11.343/06. Quanto aos sentenciados ROBERTO PEREIRA DA SILVA e MATHEUS GABRIEL PEREIRA DA HORA, condenados como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, consigno que o tráfico ilícito de drogas é crime equiparado aos hediondos, sendo vedada a aplicação dos substitutivos penais (CP, art. 44), do "sursis" ou de benesses correlatas. Deverão os sentenciados ROBERTO PEREIRA DA SILVA e MATHEUS GABRIEL PEREIRA DA HORA iniciarem o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, consoante norma cogente do artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.072/90 (com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007). ROBERTO PEREIRA DA SILVA e MATHEUS GABRIEL PEREIRA DA HORA ficaram presos cautelarmente durante o curso do processo e não têm o direito de apelarem em liberdade, pois um dos efeitos da sentença condenatória é ser o preso conservado na prisão (RHC 3.473-4, 5ª Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u. 4.4.94, p. 6691), sendo de rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Denego-lhes, pois, o apelo em liberdade, recomende-se os réus ROBERTO PEREIRA DA SILVA e MATHEUS GABRIEL PEREIRA DA HORA na prisão. Quanto ao sentenciado SANTIAGO SEPULVEDA RODRIGUEZ, houve a aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Neste ponto, ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao deferir a ordem, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, entendeu que o

chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Por conta disso, nos termos do artigo 44 do Código Penal, apenas para SANTIAGO SEPULVEDA RODRIGUEZ, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, a ser regulamentada no Juízo das Execuções, nos termos do artigo 46 do Código Penal. Na hipótese de descumprimento das condições impostas o sentenciado SANTIAGO SEPULVEDA RODRIGUEZ deverá iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto. Em virtude da concessão da pena restritiva de direito para SANTIAGO SEPULVEDA RODRIGUEZ determino que seja expedido em seu favor alvará de soltura clausulado. Os valores em dinheiro arrecadados com os réus deverão ser revertidos em favor da SENAD. A droga deve ser incinerada e destruídos demais bens apreendidos. Por conta de SANTIAGO SEPULVEDA RODRIGUEZ ser colombiano, comunique-se a presente condenação: ao Consulado da Colômbia em São Paulo; ao Ministério da Justiça; e ao Departamento de Polícia Federal. Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, saindo as partes intimadas, inclusive quanto ao prazo recursal. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu Roberto:

Réu Matheus:

Réu Santiago:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA